

‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성

The Regular Bonus with the Incumbent Condition and the Ordinary Wages

권 오 성*

Kwon, Oh Seong

목 차

- I. 문제의 제기
- II. 통상임금 해석론
- III. 상여금과 통상임금
- VI. 정기상여금과 ‘재직 조건’
- V. 결론

* 성신여자대학교 법과대학 교수

I. 문제의 제기

대법원은 2013년 갑을오토텍 사건에 대한 2개의 전원합의체 판결에서 통상임금의 판단기준을 상세하게 밝히면서,¹⁾ 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 조건이 붙은 수당은 고정성이 부정되어 통상임금에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이후에도 대법원은 지급기준일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급되는 하기휴가비와 설·추석상여금의 통상임금성을 부정하였고,²⁾ 개인연금보험료, 하기휴가비 등에 관하여 동일한 판단을 하였다.³⁾ 따라서 설·추석상여금이나 하계휴가비, 선물비, 생일지원금 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 소정근로의 제공 여부와 관계없이 특정한 시점에서의 재직여부라는 우연한 사정에 따라 지급여부가 결정되는 수당은 통상임금에 해당하지 않는다는 해석은 판례로 견고하게 정착된 것으로 보인다. 물론 이러한 판례법리는 이들 수당의 지급에 ‘재직 조건’을 붙이는 것이 허용됨을 전제로 하는 것이다. 이와 같이 ‘재직 조건’이 붙은 수당은 통상임금에 해당하지 않는다는 대법원의 판단이 있는 후, 다수의 하급심 재판에서 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금이 통상임금에 해당하는지 여부가 다투어졌는바, 정기상여금에 ‘재직 조건’이 붙었다는 이유로 통상임금에 해당하지 않는다고 판단한 판결이 다수이기는 하나,⁴⁾ ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 긍정한 판결도 있었다.⁵⁾ 이러한 상황에서 대법원은 2017. 9. 26. “지급일 현재 재직하고 있는 근로자에게만 지급되는 정기상여금은 근로자가 근로를 제공하더라도 지급일 전에 퇴직하면 당해 정기상여금을 전혀 지급받지 못하므로 소정근로에

1) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결; 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결.

2) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011다86287 판결.

3) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2012다116871 판결 및 이 판결의 환송심인 서울고등법원 2015. 10. 30. 선고 2014나28208 판결.

4) 서울중앙지방법원 2016. 1. 29. 선고 2012가합87787 판결; 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2012가합88902 판결; 서울고등법원 2016. 10. 12. 선고 2015나25909 판결; 서울고등법원 2017. 5. 12. 선고 2016나2039352 판결 등.

5) 부산지방법원 2014. 10. 10. 선고 2011가합27496 판결; 서울북부지방법원 2015. 7. 15. 선고 2014가합20572 판결 등.

대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 고정성도 인정되지 않아 통상임금에 해당하지 않는다.”는 취지의 2개의 판결을 선고하였다.⁶⁾ 위 판결들은 2013년 전원합의체 판결에서 제시한 고정성 요건을 정기상여금에도 ‘그대로’ 적용한 것인바, 과연 설·추석상여금 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 지급되는, 따라서 소정근로의 제공과의 관련성이 크지 않다고 볼 수 있는 수당들과 지급률이 고정된 정기상여금을 동일하게 취급하는 것이 정당하지 의문이다.

아래에서는 통상임금에 관한 기존의 해석론의 문제점, 상여금의 법적 성격에 관한 검토, 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 문제점을 차례로 살핀 후, 이를 토대로 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 부정한 2017년 대법원 판결들의 부당성을 논구하고자 한다.

II. 통상임금 해석론

1. 관련규정의 연혁

(1) 1953년 제정 근로기준법 및 관련 시행령

1953. 5. 10. 법률 제286호로 제정된 근로기준법(시행일: 1953. 8. 9.) 제46조는 ‘시간외휴일근로’라는 제목으로 다음과 같은 규정을 두고 있었다.

제46조 (시간외휴일근로) 사용자는 연장시간근로(第42條, 第43條의 規定에 依하여 延長된 時間의 勤勞)와 야간근로(下午10時부터 上午6時까지의 사이의 勤勞)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하여야 하며 휴일근로(本法에서 定한 賃金支給休日의 勤勞)에 대하여는 사용자는 당해일에 소당임금을 지급하는 것을 이유로 본법에서 정한 휴일에 지급할 임금의 지급을 거절할 수 없다.

한편, 1954. 4. 7. 대통령령 제889호로 제정된 근로기준법시행령(시행일: 1954.

6) 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결; 대법원 2017. 9. 26. 선고 2016다238120 판결.

4. 7.) 제24조는 ‘법 제46조의 규정에 의한 통상임금’의 구체적인 산정방식에 관하여 다음과 같이 규정하고 있었다.

제24조 법 제46조의 규정에 의한 통상임금이라 함은 다음 각호에 의하여 산정한 것을 말한다.

1. 시급으로써 정하여진 임금에 대하여는 그 금액
2. 일급으로써 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 1일의 소정 근로시간수로써 제한 금액
3. 주급으로써 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 주의 소정 근로시간수로써 제한 금액
4. 월급으로써 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 월의 소정 근로시간수로써 제한 금액
5. 월, 주이외의 일정한 기간으로써 정하여진 임금에 대하여는 전각호에 준하여 산정된 금액
6. 도급제에 의하여 정하여진 임금에 대하여는 그 임금 산정기간에 있어서 도급제에 의하여 계산된 임금의 총액을 당해 임금산정기간(임금마감일이 있는 경우에는 임금마감기간. 이하 같다)의 총근로시간수로써 제한 금액
7. 근로자가 받는 임금이 전각호의 2이상의 임금으로써 되어 있는 경우에는 그 부분에 대하여 전각호에 의하여 각각 산정된 금액의 합산액

이후 1981년에 이르기까지 근로기준법과 동법시행령이 수차례 개정되는 동안 통상임금에 관한 규정은 1969. 11. 10. 개정 근로기준법시행령(대통령령 제4220호)에서 조문의 위치가 제31조로 변경된 것 이외에 실질적인 내용의 변화는 없었다.

(2) 1982년 개정 근로기준법시행령

1982. 8. 13. 대통령령 제10898호 일부개정되어 같은 날 시행된 근로기준법시행령은 제31조 제1항을 신설하여 통상임금을 “근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액”이라고 정의하였는바, 이를 통하여 ‘정기

성’과 ‘일률성’이 통상임금의 징표 내지 개념요소로 처음 명시되었다. 한편, 동조 제2항은 시간급금액 이외의 방식으로 정하여진 임금을 시간급금액으로 산정하는 식을 규정하였는바, 이는 개정 전의 근로기준법시행령 제31조와 동일한 내용이다.

제31조 (통상임금의 정의) ①법과 이 영에서 "통상임금"이라 함은 근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액을 말한다.

②제1항의 규정에 의한 통상임금을 시간급금액으로 산정할 때에는 다음 각호에 의한다. 이 경우 일급금액으로 통상임금을 산정할 때에는 시간급금액에 1일의 소정근로시간수를 곱하여 계산한다.

1. 시간급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액
2. 일급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 1일의 소정근로시간수로 나눈 금액
3. 주급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 주의 소정근로시간수로 나눈 금액
4. 월급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 월의 소정근로시간수로 나눈 금액
5. 월·주외의 일정한 기간으로 정하여진 임금에 대하여는 제1호 내지 제4호에 준하여 산정된 금액
6. 도급제에 의하여 정하여진 임금에 대하여는 그 임금산정기간에 있어서 도급제에 의하여 계산된 임금의 총액을 당해 임금산정기간(임금마감일이 있는 경우에는 임금마감기간 이하같다)의 총근로시간수로 나눈 금액
7. 근로자가 받는 임금이 제1호 내지 제6호에서 정한 2이상의 임금으로 되어 있는 경우에는 그 부분에 대하여 제1호 내지 제6호에 의하여 각각 산정된 금액의 합산액

한편, 위 개정 조항에서 ‘정기적’, ‘일률적’이라는 자구에 한자가 병기되어 있지는 않지만 일반적인 언어관용에 비추어 ‘정기적’이라는 문구는 ‘定期的’이라는 의미로, ‘일률적’이라는 문구는 ‘一律的’이라는 의미로 사용되었을 것으로 보인다.⁷⁾

(3) 1997년 제정 근로기준법시행령

1997. 3. 27. 대통령령 제15320호로 제정된 근로기준법시행령 제6조는 통상임금의 정의는 종전의 내용을 그대로 유지하면서 시간급금액 이외의 방식으로 정하여진 임금을 시간급금액으로 산정하는 식의 분모(分母)를 종전의 ‘소정근로시간수’에서 ‘통상임금 산정기준시간수’로 변경하였다.

제6조 (통상임금) ①법과 이 영에서 "통상임금"이라 함은 근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액을 말한다.

②제1항의 규정에 의한 통상임금을 시간급금액으로 산정할 경우에는 다음 각호의 방법에 의하여 산정된 금액으로 한다.

1. 시간급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액
2. 일급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 1일의 소정 근로시간수로 나눈 금액
3. 주급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 주의 통상임금 산정기준시간수(법 제20조의 규정에 의한 주의 소정근로시간과 소정근로시간외의 유급처리되는 시간을 합산한 시간)로 나눈 금액
4. 월급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 월의 통상임금 산정기준시간수(주의 통상임금산정 기준시간에 1년간의 평균주수를 곱한 시간을 12로 나눈 시간)로 나눈금액
5. 일·주·월외의 일정한 기간으로 정하여진 임금에 대하여는 제2호 내지 제4호에 준하여 산정된 금액
6. 도급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 임금산정기간에 있어서 도급제에 의하여 계산된 임금의 총액을 당해 임금산정기간(임금마감일이 있는 경우에는 임금마감기간을 말한다)의 총근로 시간수로 나눈 금액
7. 근로자가 받는 임금이 제1호 내지 제6호에서 정한 2이상의 임금으로 되어 있는 경우에는 각 부분에 대하여 제1호 내지 제6호에 의하여 각각 산정된 금액을 합산한 금액

7) 다른 가능성으로 ‘一率’이라는 한자어도 있기는 하나, 우리나라에서는 그 활용빈도가 높지는 않다.

③제1항의 규정에 의한 통상임금을 일급금액으로 산정할 때에는 제2항의 규정에 의한 시간급 금액에 1일의 소정근로시간수를 곱하여 계산한다.

위 입법연혁에서 나타나듯, 근로기준법은 1953년 제정 당시부터 시간외근로에 대한 할증임금의 산정을 위한 기준으로 ‘통상임금’이라는 용어를 사용하면서도 통상임금이 무엇인지에 관하여는 법률에 아무런 규정을 두고 있지 않았고, 이러한 태도는 지금까지 이어지고 있다. 한편, 1994년 제정 근로기준법시행령은 일급, 주급, 월급 등이 통상임금에 해당함을 전제로 그러한 금액을 해당 기간의 소정근로시간수로 나누어 시급으로 환산할 수 있다고 규정하고 있었다. 이후 1982년 개정 근로기준법시행령에서 “근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액”이라는 통상임금의 ‘일반적인 정의’가 도입되었으며, 1997년 제정 근로기준법시행령에서 시간급금액 이외의 방식으로 정하여진 임금을 시간급금액으로 산정하는 식의 분모(分母)를 ‘통상임금 산정 기준시간수’로 변경하였다.

2. 2012년 전원합의체 판결

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결은 “어떠한 임금이 통상임금에 속하는지 여부는 그 임금이 소정근로의 대가로 근로자에게 지급되는 금품으로서 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 것인지를 기준으로 그 객관적 성질에 따라 판단하여야 하고, 임금의 명칭이나 그 지급주기의 장단 등 형식적 기준에 의해 정할 것은 아니다.”라고 판단하였다.

대법원은 위 판결에서 ‘정기적’이란 말의 의미를 “통상임금에 속하기 위한 성질을 갖춘 임금이 1개월을 넘는 기간마다 정기적으로 지급되는 경우, 이는 노사간의 합의 등에 따라 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로의 대가가 1개월을 넘는 기간마다 분할지급되고 있는 것일 뿐, …… 정기상여금과 같이 일정한 주기로 지급되는 임금의 경우 단지 그 지급주기가 1개월을 넘는다는 사정만으로 그 임금이 통상임금에서 제외된다고 할 수는 없다.”고

보았고, ‘일률적’이란 말의 의미를 “‘일률적’으로 지급되는 것에는 ‘모든 근로자’에게 지급되는 것뿐만 아니라 ‘일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자’에게 지급되는 것도 포함된다.”고 보면서, 여기서 ‘일정한 조건’이란 “고정적이고 평균적인 임금을 산출하려는 통상임금의 개념에 비추어 볼 때 고정적인 조건이어야 한다.”고 보았다.

한편, 대법원은 “통상임금이 위와 같이 근로자가 사용자와 사이에 법정근로시간의 범위에서 정한 근로시간(이하 ‘소정근로시간’이라고 한다)을 초과하는 근로를 제공할 때 가산임금 등을 산정하는 기준임금으로 기능한다는 점을 고려하면, 그것은 당연히 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로의 가치를 금전적으로 평가한 것이어야 하고, 또한 근로자가 실제로 연장근로 등을 제공하기 전에 미리 확정되어 있어야 할 것이다.”라고 판시하고, 나아가 “... ‘고정성’이라 함은 ‘근로자가 제공한 근로에 대하여 그 업적, 성과 기타의 추가적인 조건과 관계없이 당연히 지급될 것이 확정되어 있는 성질’을 말하고, ‘고정적인 임금’은 ‘임금의 명칭 여하를 불문하고 임의의 날에 소정근로시간을 근무한 근로자가 그 다음 날 퇴직한다 하더라도 그 하루의 근로에 대한 대가로 당연하고도 확정적으로 지급받게 되는 최소한의 임금’이라고 정의할 수 있다.”고 판시하여 소위 ‘사전확정성’ 내지 ‘고정성’을 통상임금의 요건으로 요구하였다.

3. 기존 해석론의 문제점

(1) 1997년 제정 근로기준법시행령은 통상임금의 시간급 환산식의 분모(分母)를 종전의 ‘소정근로시간수’에서 해당 임금산정 기간의 소정근로시간과 ‘소정근로시간외의 유급처리되는 시간’을 더한 ‘통상임금 산정기준시간수’로 변경하였다. 이러한 입법은 ‘소정근로시간외의 유급처리되는 시간’에 대하여 지급되는 급여가 통상임금에 포함됨을 전제한 것이다. 그런데, 통상임금은 기본적으로 소정근로시간을 넘는 근로(편의상 “소정외 근로”라고 한다)에 대한 수당의 산정의 기준금액이다. 따라서 ‘소정근로시간외의 유급처리되는 시간’에 대한 급여(예컨대, 주휴수당)는 통상임금에 포함되는 임금이 아니라 통상임금을

‘적용’하여 지급하여야 하는 수당으로 보아야 할 것이다.

(2) ‘시간급, 일급, 주급, 월급’이라는 용어 그 자체에 정기성(定期性)과 일률성(一律性)이라는 개념징표가 당연히(in nature) 내재되어 있다는 점을 고려할 때(예컨대, 월급금액의 경우 ‘월급(月給)’이라는 말 자체가 이미 월의 소정근로에 대하여 매월(定期的) 일정한 지급률(一律的)로 지급하기로 정하여진 금액을 의미한다), 근로기준법시행령 제6조 제1항의 “근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액”이라는 통상임금의 정의에서 ‘정기적·일률적’라는 문구가 어떠한 의미로 사용된 것인지 의문이다. ‘정기성·일률성’이 인정되지 않은 ‘시간급, 일급, 주급, 월급’은 상상하기 어렵기 때문이다. ‘일·주·월’외의 일정한 기간으로 정하여진 임금의 경우에도 사정은 다르지 않다. 따라서 시간급, 일급, 주급, 월급, 일·주·월외의 일정한 기간으로 정하여진 임금은 본질적으로(per se) 통상임금이다. ‘정기성·일률성’과 ‘시간급, 일급, 주급, 월급’은 동어반복(tautology)에 불과하다.

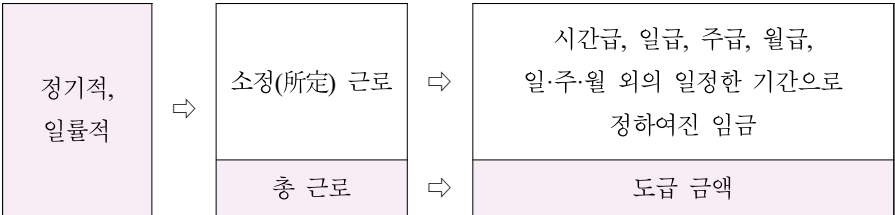
(3) 근로기준법시행령 제6조 제1항에서 말하는 ‘일률적(一律的)’의 의미는 과연 무엇인가? 국립국어원의 표준국어대사전에 따르면 ‘일률적(一律的)’이라는 말은 ‘태도나 방식 따위가 한결같은’이라는 의미를 갖는다. 그렇다면 ‘일률적’으로 지급되는 임금이라는 말은 결국 ‘하나의 비율’에 따라 근로시간의 증가에 비례적으로 지급하기로 정한 임금을 의미하는 것으로 이해해야 하는 것이 아닐까? 이러한 관점에서 보면 ‘일률성’이라는 문구를 ‘모든 근로자’ 또는 ‘일정한 조건을 충족한 근로자’ 등의 의미로 이해해온 판례는 일률적(一律的)이라는 말을 ‘하나도 빠짐없이’라는 의미로 오독(誤讀)한 것이다. 통상임금은 사용자와 개별 근로자 사이에서 발생하는 연장근로 등에 관한 수당의 계산을 위한 도구개념이다. 개별 근로자의 연장근로수당을 계산함에 있어 다른 근로자가 어떠한 조건에서 얼마의 임금을 받기로 하였는가는 ‘아무런’ 관계가 없다. 일률적(一律的)이란 말은 글자 그대로 ‘하나의 비율(一律, flat rate)’을 의미하는 것으로 글자 그대로 읽어야 한다.

(4) 근로기준법시행령 제6조 제1항에서 말하는 ‘정기적(定期的)’의 의미는 과연 무엇인가? 근로기준법은 매월 정기일 지급의 원칙을 규정하고 있다. 소

정근로에 대한 임금은 당연히 1개월을 넘지 않는 기간을 주기로 ‘정기적’으로 지급되어야 한다. 소정근로에 대한 임금이 이러한 1개월 이내의 기간을 주기로 정기적으로 지급되지 않는 경우 이는 근로기준법에 위반한 임금지급방식으로 위법하다고 평가되어야 한다. 이러한 형태로 지급되는 임금을 정기성을 결하였다고 보아 통상임금에 해당하지 않는다고 판단하는 것은 선후가 바뀐 판단방식이다. 사용자가 근로자에게 비정기적으로 또는 1개월을 넘는 기간을 주기로 지급하는 금품의 경우 그러한 금품지급이 매월 정기일 지급의 원칙의 예외에 해당하는지를 먼저 판단해야 하는 것이지, 그러한 판단을 생략한 채 위법한 사실을 전제로 통상임금에 해당하는지에 여부를 평가하는 것은 탈법 내지 불법을 자행한 사용자를 오히려 더 보호하는 부당한 결과를 가져온다.

(5) 시간급, 일급, 주급, 월급, 일·주·월외의 일정한 기간으로 정하여진 임금은 ‘당연히’ 통상임금에 해당한다면, 통상임금의 개념요소로 ‘정기성’과 ‘일률성’을 규정한 근로기준법시행령 제6조 제1항은 규범적으로 어떤 의미를 갖는가? 이해의 편의상 근로기준법 시행령 제6조 제1항의 문구를 아래 그림과 같이 재구성해 본다.

<그림 1> 근로기준법시행령 제6조 제1항의 재구성



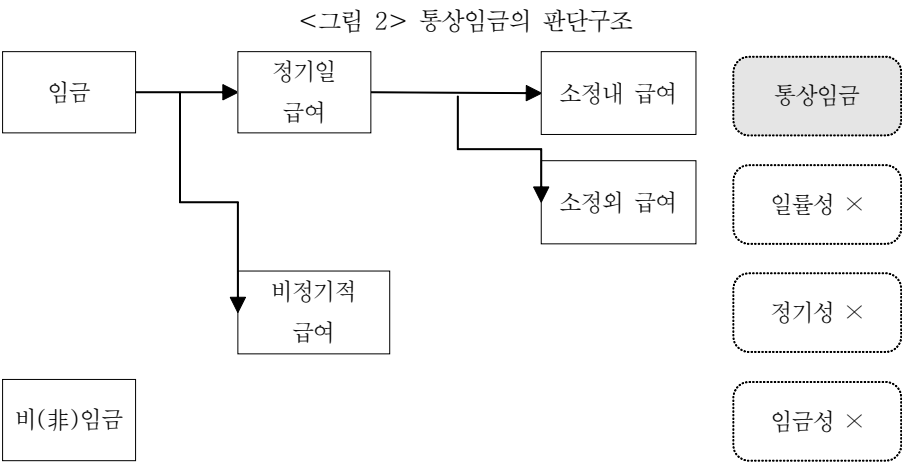
‘시간급, 일급, 주급, 월급’이라는 용어 자체에 ‘정기성·일률성’이라는 의미가 당연히 포함되어 있다고 본다면, ‘정기적·일률적’이라는 말은 ‘총 근로에 대하여 지급되는 도급 금액’에 관해서나 의미를 갖는다고 할 것이다. 그렇다면, 총 근로에 대한 도급금액도 ‘정기적·일률적’인 경우에만 통상임금에 해당하는가? 근로기준법시행령 제6조 제2항 제6호는 시간급 통상임금액의 산정방법을 “도급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 임금산정기간에 있어서 도

급제에 의하여 계산된 임금의 총액을 당해 임금산정기간(임금마감일이 있는 경우에는 임금마감기간을 말한다)의 총근로시간수로 나눈 금액”이라고 규정하고 있다. 과연 ‘도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자’(이하 “도급근로자”라 한다)⁸⁾가 제공한 총근로에 대하여 도급금액으로 정해진 임금이 ‘정기적·일률적’일 수 있는가? 총 근로에 대하여 도급금액으로 정해진 임금은 근로시간과의 관계에서 어떠한 함수관계에 있지 않으며, 따라서 근로시간과 임금 사이에 일률성을 갖기 어렵다. 따라서 도급근로자의 시간급 통상임금은 사후적으로 평가될 수밖에 없다.

필자는 통상임금은 “①임금성 → ②정기성 → ③일률성”의 3단계의 판단구조를 따라야 한다고 생각하며, 법문에서 규정하지 않는 ‘고정성’은 별도로 고려되어서는 아니 된다고 생각한다. 판례가 언급하는 ‘고정성’은 일률성(一律性)의 내용을 구성하는 요소로 고려될 수 있을 뿐이지, 통상임금 여부를 판단하는 ‘요건’으로 보아서는 아니된다. 법령이 예정하지 않은 ‘고정성’이라는 모호한 개념을 통상임금의 요건의 하나로 추가하는 것은 통상임금의 범위를 당초 입법자가 예상보다 부당하게 좁히는 것으로 해석의 범위를 넘는 부당한 법형성이라고 생각된다. 한편 ‘사전확정성’이라는 개념을 ‘내일 퇴사하는 경우에도 무조건 지급되는 금품’ 따위로 마치 수학적 인과성과 동일한 차원으로 해석하는 것 또한 당연히 법령에 근거가 없다. 근로기준법 시행령 제6조 제1항은 통상임금을 소정근로 또는 총근로에 대하여 ‘지급하기로 정하여진’ 임금이라고 정의한다. 따라서 통상임금은 근로자가 당초 약정한 소정근로가 제공하는 ‘통상적인’ 경우에 지급하기로 미리 정하여진 ‘통상적인’ 임금일 뿐이지, 소정근로가 실제로 제공되지 않은 ‘이례적인’ 경우 당초 지급하기로 약속된 임금이 ‘사후적’으로 감액하여 지급되었다는 이유로 그러한 임금의 통상임금

8) 근로기준법 제2조 제2항 제7호는 “소정근로시간이란 …… 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간을 말한다.”고 규정하고 있다. 따라서 소정근로시간을 정한 경우 이러한 소정근로시간에 제공할 근로에 대한 대가는 그 시간에 비례하는 ‘시간급, 일급, 주급, 월급’으로 정해야 할 것이다. 반면, 근로계약에서 소정근로시간을 정하지 않는 경우(대부분 도급근로자에 해당할 것이다)에는 당사자 간에 약속한 총 근로에 대한 대가를 총액으로 정할 수밖에 없을 것이다. 근로기준법 제47조는 이러한 도급근로자의 임금의 보호를 위하여 “사용자는 도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.”고 규정하고 있다.

성이 부정될 수는 없는 것이다.



Ⅲ. 상여금과 통상임금

1. 상여금의 의의와 법적 성격

(1) 상여금의 의의

우리나라의 일반적인 언어관용으로 상여금은 정기적인 임금 외에 분기별 또는 1년에 수회의 특정한 시기에 기본급 또는 기본급에 일정한 수당을 포함한 금액에 일정 비율을 곱하여 산정한 금액을 지급하는 금품이라는 의미로 사용되고 있다. 물론 이러한 의미로 사용되는 상여금이라는 용어는 법률용어가 아니다. 근로기준법은 상여금에 대한 정의규정을 두고 있지 않고, 다만 근로기준법시행령 제23조 제3호에서 임시로 지급하는 임금 등의 하나로 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”을 규정하고 있을 뿐이다.⁹⁾

한편, ‘상여금(賞與金)’이라는 말을 문자 그대로 풀어보면 상여(賞與)란 ‘상

으로 준다’라는 의미이므로, 상여금은 근로제공의 대가나 그 보상(報償)으로 지급되는 금품이 아니라 근로자의 공로나 업적에 대한 포상(褒賞)으로 지급하는 금품으로 이해하여야 할 것이다.¹⁰⁾ 따라서 문자 그대로의 의미의 ‘상여금’은 본질적으로 그 지급여부나 지급액이 가변적일 수밖에 없는 것이다.

(2) 상여금의 임금성

근로기준법 제2조 제1항 제5호는 임금을 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품”이라고 정의하고 있는바, 사용자가 ‘상여금’이라는 명칭으로 근로자에게 지급하는 금품이 이러한 임금의 개념에 포섭되는지 문제된다. 상여금의 임금성은 종래 주로 상여금의 명목으로 지급된 금원이 퇴직금의 산정을 위한 평균임금의 산정에 포함되는지 여부를 중심으로 다투어졌다. 상여금의 임금성과 관련하여 상여금 명목으로 지급되는 금품이라도 계속적·정기적으로 지급되고 지급액이 확정되어 있는 경우는 임금이지만, 경영의 성과 등 불확실한 사유에 따라 일시적으로 지급되는 경우는 임금으로 인정되지 않는다는 견해가 있으며,¹¹⁾ 대법원도 “상여금이 임금후불적 성질의 것인지 또는 은혜적, 포상적 성질의 것인지는 확일적으로 분류할 수 없는 것이기는 하나 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 일시적으로 지급되는 것을 제외하고는 일반적으로 근무자에 대한 근무의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지는 것이라고 해석하여야 할 것”이라고 판단한 사례가 있다.¹²⁾

이와 같이 지급여부가 불확정적이거나 일시적으로 지급되는 상여금의 경우에는 그 임금성에 관하여 논란이 있을 수 있겠으나, 적어도 고정금 형태로 계

9) 권오성, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 『노동법논총』, 제41집, 한국비교노동법학회, 2017. 12, 13-14면.

10) 김홍영, “상여금의 임금성 여부”, 『노동법연구』, 제21호, 서울대학교 노동법연구회, 2006. 12, 70면.

11) 임종률, 노동법(제14판), 박영사, 2016, 397-398면. 김유성 교수도 “구체적인 지급기준을 정함이 없이 그 지급이 사용자의 재량에 맡겨져 있거나 경영의 성과에 따라 일시적·불확정적으로 지급되는 경우에는 임금으로 인정되지 않는다.”고 한다(김유성, 노동법I, 법문사, 2005, 80면).

12) 대법원 1982. 11. 23. 선고 81다카1275 판결. 같은 취지의 판결로 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003다27429 판결 등.

속적·정기적으로 지급되는 상여금이 임금, 즉 근로의 대가에 해당한다는 점에 대하여는 유의미한 이견(異見)을 찾아보기 어렵다.

(3) 정기상여금의 소정근로 대가성

고정급 형태의 정기상여금은 해당 정기상여금의 지급기간의 소정근로는 물론 연장근로나 휴일근로 등 ‘모든’ 근로에 대한 가치를 반영한 것이라는 견해가 있다.¹³⁾ 그러나 김성진 교수가 적절히 지적한 것처럼 연장근로나 휴일근로는 통상적인 근로가 아님은 물론 정기상여금이 정해지는 시기에는 연장근로나 휴일근로 여부가 예정되어 있지 않다는 점에서 정기상여금을 총근로의 대가로 이해하는 견해는 동의하기 어렵다.¹⁴⁾ 따라서 적어도 ‘고정급 형태의 정기상여금’은 기본적으로 그 산정기간에 근로자가 제공하기로 약속한 소정근로에 대한 대가로 보는 것이 옳다고 생각한다.

한편 정기상여금이 근로의 대가 외에 ‘공로보상’ 내지 ‘생활보전’의 성질을 갖는다는 견해가 있는바, 이는 정기상여금에 관한 한국과 일본의 차이를 간과한 것이라고 생각한다. 일본의 경우에는 노동기준법 제11조가 임금, 급여, 수당, ‘상여’ 그밖에 명칭 여하를 묻지 아니하고 근로의 대상으로서 사용자가 노동자에 지급하는 모든 것을 임금으로 규정하여 명문으로 ‘상여’가 임금에 해당함을 규정하고 있는바, 이러한 상황에서 상여의 법적 성격을 기본적으로 지급대상기간의 근로에 대응하는 임금이지만, 이에 공로보상의 성격과 생활보전의 성격 및 장래의 근로에 대한 의욕향상으로서의 성격도 함께 갖는다고 이해하는 것이 주류적인 견해이다.¹⁵⁾ 다만 일본의 경우 노동기준법 시행 직후부터 ‘정기적으로 지급되고 또한 지급액이 확정되어 있는 것’은 상여에 해당하지 않는다는 입장이 명확하였기 때문에 일본에서의 상여의 법적 성격에 관한 논의는 지급여부나 지급액이 가변적인 ‘본래 의미의 상여’에 관한 것으로 제한

13) 예컨대 하경효 교수는 상여금이 분기 또는 1년의 소정근로에 대하여 지급하기로 한 분기급 또는 연급(연봉)으로서의 성질을 가지는 것은 아니라고 주장한다(하경효, 임금법제론, 신조사, 2013, 87면).

14) 김성진, “통상임금의 본질개념으로서의 통상성”, 『노동법포럼』, 제11호, 노동법이론실무학회, 2013. 10, 287면.

15) 菅野和夫(이정 역), 일본노동법, 법문사, 2007, 212면.

적으로 이해하여야 할 것이다.¹⁶⁾

(4) 임금정기일 지급의 원칙과 정기상여금

근로기준법 제43조 제2항은 ‘임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다.’고 규정한다. 위 조항은 임금지급의 간격이 지나치게 넓어지거나 부정기적으로 행해짐으로써 초래되는 근로자의 생활상의 불안을 제거함을 목적으로 한다.¹⁷⁾ 따라서 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 ‘근로의 대가’의 성격을 갖는다면 이러한 금품은 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금에 해당하고, 따라서 그러한 금품이 근로기준법시행령 제23조의 각호에 해당하지 않는 한 근로기준법 제43조 제2항 본문에 따라 매월의 정기임금일에 지급되어야 한다.

이와 관련하여 근로기준법 시행령 제23조 제3호는 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”이라고 규정하고 있어, 고정급의 정기상여금도 일견 동호에 해당하는 것으로 해석될 여지가 있어 보이나, 근로기준법 시행령 제23조 제3호의 상여금은 1개월을 초과하는 기간에 걸쳐 기업의 경영실적, 근로자의 근무성적 등의 사유에 따라 산정하여 지급하는, 따라서 본질적으로 그 지급여부 및 지급금액이 가변적인 금품만을 의미하는 것으로 ‘제한적’으로 해석되어야 할 것이다. 따라서 기본급에 일정한 비율을 곱하여 산정한 금액을 정기적으로 지급하는 형태의 고정급의 정기상여금은 위 조항이 당초 예정한 상여금으로 보기 어렵다. 대법원도 상여금의 지급일 전에 퇴직한 근로자가 퇴직일 이전에 근무한 기간에 상응하는 상여금을 청구할 수 있는지가 다투어진 대법원 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결에서

16) 일본의 경우 상여는 통상 「기본급×지급률×출근율」의 식으로 계산되며, 여기에 인사고과에 의한 ‘성적계수’를 곱하는 기업도 많다는 설명으로 菅野和夫(이정 번역), 고용사회와 노동법, 박영사, 2001, 159면.

17) 정현수, “임금채권의 보호”, 『재판자료 제39집: 근로관계 소송상의 제문제(상)』, 법원도서관, 1987, 533면. 하경효, 앞의 책, 168면. 한편, 고용노동부는 「임금의 매월 1회 이상 정기지급 원칙에 관한 해석기준」에서 “임금의 ‘매월 1회 이상 정기지급’ 원칙을 규정하고 있는 법의 취지는 사용자로 하여금 적어도 매월 한 번은 일정한 날짜를 미리 정하여 근로의 대가를 지급하게 함으로써 근로자의 생활안정을 도모”하는 데 있다고 밝힌바 있다.

상여금이 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 ‘임시지급의 임금’으로 볼 수 없고 ‘정기일지급 임금’에 해당한다고 판시한바 있다.

“근로기준법 제36조 제2항¹⁸⁾의 규정에 의하면, 임금에는 매월 1회 이상 일정 기일에 지급하는, 이른바 정기일지급원칙의 적용을 받는 임금 외에도 예외적으로 임시로 지급하는 임금이 있고, 같은 법 시행령 제18조¹⁹⁾에 보면 이러한 예외적인 임시지급의 임금으로서, 1) 1월을 초과하는 기간의 출근성적에 의하여 지급되는 정근수당, 2) 1월을 초과하는 일정기간의 계속 근무에 대하여 지급되는 근속수당, 3) 1월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 의하여 산정되는 장려가급·능률수당 또는 상여금, 4) 기타 부정기적으로 지급되는 제수당 등을 열거하여 규정하고 있는바, 이러한 임시지급의 임금은 그 지급사유의 발생이나 성격이 임시적이거나 불확정적인 것에 한하는 것이며, 상여라는 명칭으로 지급되는 금원이라도 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있는 것은 여기에 해당하지 않는 것이다.”(밑줄은 필자)

따라서 엄격한 의미의 상여금, 즉 근로기준법시행령 제23조 제3호에 따라 임금 매월 정기일 지급의 원칙의 적용이 배제되는 ‘임시지급의 임금’으로서의 상여금은 1개월을 초과하는 기간에 걸쳐 기업의 경영실적, 근로자의 근무성적 등을 기준으로 산정되는, 따라서 본질적으로 그 지급여부나 지급액이 변동적인 금품만을 의미한다. 이러한 해석에 의하면, 근로의 대가로 정기적으로 지급되는, 그리고 그 지급액이 고정된 금품은 근로기준법 시행령 제23조 제3호 소정의 ‘상여금’의 개념에 포섭될 수 없으므로, 정기상여금이라는 명목으로 지급되는 임금 중 ‘정기적·일률적’로 지급되고 지급액이 ‘고정’되어 있는 상여금, 즉 고정급의 정기상여금은 ‘정기일지급 임금’에 해당하며, 따라서 수개월의 간

18) 1974. 12. 24. 법률 제2708호로 일부개정된 근로기준법 제36조 제2항은 “임금은 매월 1회이상 일정한 기일을 정하여 지급하여야 한다. 다만 임시로 지급하는 임금, 수당 기타 이에 준하는 것 또는 대통령령으로써 정하는 임금에 대하여는 예외로 한다.”고 규정하고 있었다.

19) 1975. 4. 28. 대통령령 제7613호로 일부개정된 근로기준법시행령 제18조는 근로기준법 제36조 제2항 단서의 규정에 의한 임금·수당으로 ① 1월을 초과하는 기간의 출근성적에 의하여 지급되는 정근수당(제1호), ② 1월을 초과하는 일정기간의 계속근무에 대하여 지급되는 근속수당(제2호), ③ 1월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 의하여 산정되는 장려가급·능률수당 또는 상여금(제3호), ④ 기타 부정기적으로 지급되는 제수당(제4호)을 열거하고 있었다.

격으로 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항 본문에 위반하는 것이다. 따라서 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가로 지급하는 ‘정기일지급 임금’에 해당하며,²⁰⁾ 따라서 수개월의 간격으로 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리²¹⁾에 따라 정기상여금 명목의 금품을 안분하여 매월의 정기지급일에 지급하는 취지의 약정으로 전환될 수 있을 뿐이라고 생각한다.

2. 비교법적 고찰

(1) 일본

1) 상여금 지급 관행의 형성²²⁾

에도(江戸) 시대의 상가(商家)에서는 설과 백중을 전후하여 고용인이 휴가를 얻어 귀향하는 때 오시키세(お仕着せ)라고 불리는 의복과 함께 용돈을 주는 관습이 있었고, 이러한 관습이 상여의 기원이 되었다는 견해도 있다(사회관습설). 한편, 메이지(明治) 시대 초기에는 직원(職員)과 공원(工員)은 신분적으로 뚜렷이 구분되었는데, 임금지급에 있어서도 상급직원(上級職員)은 연봉제, 일반직원(一般職員)은 월급제, 공원(工員)은 시간급, 일급 또는 청부급(請負給)으로 관리되었다. 상급직원과 일반직원의 경우에는 실적이 오르면 상여(賞与)가 대폭 지급되었으나, 공원(工員)에게는 상여가 지급되지 않았다. 메이지 시대 후기에 이르러 근대 공업이 방직공업 등을 중심으로 발전하고 성과급(出來高給)이 보급되자 장기근무를 장려하기 위하여 근속장려금(勤続獎勵金) 명목으로

20) 도재형, “통상임금의 범위-상여금을 중심으로-”, 『노동법연구』, 제7호, 서울대학교 노동법연구회, 1998. 5, 342면.

21) 민법 제138조(무효행위의 전환) 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 효력을 가진다.

22) 公益財団法人 連合総合生活開発研究所, 『日本の賃金－歴史と展望－』, 2012. 5, 46-50면 참조.

근속(勤續)에 따라 공원(工員)에게도 상여가 지급되기 시작했다. 다이쇼(大正) 시대가 되면서 직원 및 일부 역부공원(役付工員)에게 지급되던 상여를 평공원(平工員)이 요구하기 시작하면서 일부 대기업의 경우에 공원(工員)에게도 오늘날과 같은 상여가 지급되었다. 쇼와(昭和) 시대에는 직원(職員)의 경우 상여는 매월급여의 연간 총액의 80%로 크지만, 공원(工員)에게는 3~5%의 수준이었다. 공원(工員)에게 정기적인 상여지급이 명기된 것은 2차대전 중이었다. 2차대전의 종전을 앞둔 1945년 4월 후생성(厚生省)이 작성한 「근로자(공원)급여제도의 지도에 관한 건(勤勞者(工員)給与制度の指導に關する件)」에서 상여를 정기상여(定期賞与), 특별상여(特別賞与), 임시상여(臨時賞与)로 구분하고 정기상여에 대해서는 연 2회 직계(職階) 및 근무성적에 따라 지급하는 것으로 명기되어있다. 한편, 종전 후인 1951년에는 「국가공무원의 기말·근면수당 및 장려수당(國家公務員の期末・勤勉手當及び獎勵手當)」에 관한 권고에 따라 매년 6월과 12월, 연 2회의 일시금 지급이 퍼졌다.

2) 공장법 시대의 법안

일본의 明治13年(1880년)의 공장법안(工場法案) 제17조는 직공규칙(職工規則)에 규정할 사항으로 “상여, 징계에 관한 규정(賞与, 懲戒ニ關スル規程)”이라고 규정하여 상여(賞与)와 징계(懲戒)를 하나의 호에서 규정하고 있었고,²³⁾ 동 법안의 제25조도 도제규칙(徒弟規則)에 규정할 사항으로 “상여, 징계에 관한 규정(賞与, 懲戒ニ關スル規程)”이라고 동일하게 규정하고 있었다. 한편, 大正12(1923)의 공장법시행령동시행규칙개정안요항(工場法施行令同施行規則改正案要項)에서는 취업규칙(就業規則)에 규정할 사항으로 “상여 또는 제재에 관한 정함이 있는 경우에는 그 사항(賞与又ハ制裁ニ關スル定アルトキハ其ノ事項)”이라고 규정하고 있었다.²⁴⁾ 이와 같이 상여(賞与)라는 말은 본래 징계(懲戒) 내지 제재(制裁)와 병치되어 사용되는, 지금으로 치면 표창(表彰)의 의미로 사

23) 「第三回農商工高等會議議事速記録」(農商工高等會議, 明治32年) 5-14頁(野原香織, “日本工場法における就業規則法制の成立”, 『法學研究論集』第44号, 2016. 2, 206면에서 재인용).

24) 國立公文書館所藏「工場法施行令改正參考資料・大正14年」, “工場法施行令同施行規則改正案要項”(野原香織, 앞의 글, 212면에서 재인용).

용되는 용어였다.

3) 노동기준법 제정 이후

노동기준법이 제정된 직후인 1947년에 이미 “정기적으로 지급되고 또한 지급액이 확정되어 있는 것은 상여로 보지 않고, 정기 또는 임시로 근로자의 근무성적에 상응하여 지급되어 그 지급액이 확정되어 있지 않은 것만을 상여로 본다”는 행정해석이 명확하게 제시되었다.

노동기준법의 시행에 관한 건²⁵⁾

[법 제24조 관계] 상여(賞与)란, 정기 또는 임시로, 원칙적으로 근로자의 근무성적에 따라서 지급되는 것이며, 그 지급액이 미리 확정되지 않은 것을 말한다. 정기적으로 지급되고, 그 지급액이 확정되어 있는 것은 명칭의 여하에도 불구하고 이를 상여로 보지 않는다. 따라서, 시행규칙 제8조에 해당하지 않는 것은 법 제24조 제2항의 규정에 따라 매월 지불되어야 한다.

이처럼 일본에서는 지급액이 가변적인 본래의 의미의 상여의 경우에는 임금 매월 정기일 지급의 원칙의 적용이 배제되지만, 정기적으로 지급되고 또한 그 지급액이 확정된 금품은 그 명칭에도 불구하고 상여로 보지 않는다. 따라서 지급액이 확정되어 있지 않은 상여의 경우에는 ‘임금 매월 정기일 지급의 원칙’이 배제되나, 정기적으로 지급액이 확정되어 지급되는 금품은 그 명칭의 여하에 관계없이 일본 노동기준법 제24조 제2항에 따라 매월 지불되어야 하는 것으로 해석된다.²⁶⁾

한편, 노동기준법시행규칙 제21조는 가족수당, 통근수당, 별거수당, 자녀교

25) 労働基準法の施行に關する件(노동기준법의 시행에 관한 건), 1947(昭22). 9. 13, 發基 17号:

【法第二四條關係】賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝらず、これを賞与とはみなさないこと。従つて、かゝるもので施行規則第八條に該当しないものは、法第二四條第二項の規定により毎月支拂われなければならないこと。(厚生労働省労働基準局 編, 労働基準法解釋總覽(改訂15版), 労働調査會, 2014, 258면).

26) 片岡昇(송강직 역), 노동법, 삼지원, 1995, 485면.

육수당, 주택수당, 임시로 지불된 임금, 1개월을 넘는 기간마다 지불되는 임금은 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에 포함되지 않는다고 규정하고 있으므로, 1개월을 넘는 기간마다 지불되는 상여금은 원칙적으로 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에 포함되지 않지만, 정기적으로 지급액이 확정되어 지급되는 상여금은 노동기준법 제24조 제2항에 따라 매월 지불되어야 하므로 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에 포함될 것이다. 일본의 하급심 판결 중에는 원래 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에 산입하여야 할 수당을 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에서 제외하기 위하여 종래 1개월 마다 지급한 무사고수당, 출근수당에 관하여 그 액수를 2배로 하여 2개월 마다 지급하기로 정한 단체협약은 무효이고, 이러한 임금은 ‘할증임금의 기초가 되는 임금’에 산입된다고 판시한 것이 있다.²⁷⁾

(2) 미국

공정근로기준법(Fair Labor Standards Act, FLSA) 제7조(a)(1)은 사용자는 1주에 40시간을 초과한 근로에 대해서는 그의 통상임금률(regular rate)의 1.5배 이상의 비율로 보상(compensation)을 지급해야 한다는 취지의 규정을 두고 있다. 여기서 통상임금률(regular rate)은 1시간당으로 계산한다. 주급제 및 월급제인 경우에는 주당의 임금액을 주의 소정근로시간수(소정근로시간수가 정해져 있지 않은 경우에는 실근로시간수)로 나누어서 계산한다. 위험수당이나 교대(shift)수당 등이 추가될 경우 그 추가된 수당부분도 포함하여 주의 임금총액을 주의 실근로시간수로 나눈다. 한편, 근로자의 통상임금률은 근로에 대한 모든 보수를 포함하되, 제7조(e)(3)(a)는 일정한 요건에 해당하는 상여금(bonus)은 통상임금률의 산정에 포함되지 않는다고 규정하고 있다.²⁸⁾

27) 日本液体運輸事件: 東京地判 1981(昭56). 1. 23, 勞民集 32卷 6号.

28) 29 U.S. Code § 207 - Maximum hours

“Regular rate” defined as used in this section the “regular rate” at which an employee is employed shall be deemed to include all remuneration for employment paid to, or on behalf of, the employee, but shall not be deemed to include—

(3) Sums paid in recognition of services performed during a given period if either,

(a) both the fact that payment is to be made and the amount of the payment are determined

제7조(e) 본조에 있어서 근로자의 통상임금률은 근로에 대한 대가로 근로자에게 지급되는 모든 보수를 포함한다. 다만 다음의 것은 포함되지 않는다.

- (3) 일정한 기간의 근무에 대한 포상으로서 지급되는 금전으로, 다음 중의 어느 하나에 해당하는 것.
 - (a) 지급의 여부와 지급금액의 전적으로 사용자의 재량(sole discretion of the employer)에 의해서 결정되고, 근로자에게 정기적인 지급에 대한 기대를 야기하는(causing the employee to expect such payments regularly) 사전의 계약, 합의, 약속에 근거하고 있지 않은 경우²⁹⁾

제7조(e)(3)에 해당하여 통상임금률(regular rate)에 포함되지 않는 상여금을 ‘재량상여금’이라고 하고, 반대로 제7조(e)(3)에 해당되지 않아 통상임금률(regular rate)에 포함되는 상여금을 ‘비재량상여금’이라고 한다. 한편, 미국 노동부는 29 C.F.R. §§778.208 - 778.215에서 통상임금률에 포함되는 상여금의 범위와 통상임금률의 계산방법에 관하여 상세한 행정해석을 제시하고 있는바, 이 중 29 C.F.R. § 778.208은 통상임금률에 포함되지 않는 상여금(discretionary bonus)과 포함되지 않는 상여금(nondiscretionary bonus)의 구별 기준을 구체적으로 제시하고 있는바,³⁰⁾ 이에 의하면 ①근로자가 상여금의 지급에 대하여 어떠한 기대권을 갖지 못하고(no expectation of payment), ②사용자가 상여금의 금액과 지급시기에 관한 재량권(discretion regarding the amount and timing of payment)을 보유하고, ③상여금의 지급이 특정한 기준이나 목표의 달성과 관계되지 않으며(not tied to meeting specific standards or goals), ④상여금의 지급이 연장근로수당의 계산에 영향을 주지 않는 경우(no effect on overtime rate calculations)에는 그러한 상여금이 통상임금률 산정에 포함되지 않지만, ①상여금의 지급에 관하여 근로자의 기대권이 있거나(an expectation of payment), ②상여금의 금액과 지급시기에 관한 재량권이 없거나, ③상여금의

at the sole discretion of the employer at or near the end of the period and not pursuant to any prior contract, agreement, or promise causing the employee to expect such payments regularly;
 29) 번역은 이승길, 미국의 노동법제, 한국경영자총협회, 2005, 330면 이하를 저본으로 하여 약간의 수정을 가하였다.

30) 29 C.F.R. §778.208 Inclusion and exclusion of bonuses in computing the “regular rate.”

지급이 근로자의 성과 기타 다른 구체적인 지급조건(employee performance or other specific standards or goals)에 연동된 경우에는 통상임금을 산정에 포함된다.

IV. 정기상여금과 ‘재직 조건’

1. ‘재직 조건’의 문제점³¹⁾

(1) ‘재직 조건’의 법적 성질

상여금이나 수당의 지급약정에 붙은 ‘재직 조건’의 법적 성질에 관해서는 이를 ①본래 근로자에게 지급하도록 정해져 있는 임금채권을 소멸시키는 조건으로 이해하는 견해와 ②임금의 구성항목, 지급방법 등을 정해 둔 것이라거나 개별 수당의 지급조건을 정함으로써 임금채권의 내용을 구체화한 것일 뿐 이미 발생한 임금청구권의 효력을 상실하게 하는 조건이 아니라 이러한 조건이 성취되어야 청구권이 발생하는 것이라고 이해하는 견해가 가능할 것이다.³²⁾ 이와 관련하여 설·추석상여금이나 하계휴가비, 선물비 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 소정근로의 제공 여부와 관계없이 특정한 시점에 재직하고 있었는가라는 우연한 상황에 따라 지급여부가 결정되는 수당에 붙은 ‘재직 조건’의 경우에는 이를 ②와 같이 이해하는 것도 가능할 수 있겠지만, 고정급의 정기상여금과 같이 ‘근로의 대가’로 지급되는 성격이 뚜렷한 임금채권의 성립에 관하여 근로의 제공 이외에 당해 금품의 지급일의 재직여부라는 우연한 사정을 그러한 임금채권의 성립요건으로 보기는 어렵다고 생각한다.

근로계약은 낙성계약이지 요물계약(要物契約)이 아니므로 임금채권은 사용

31) 이 부분은 권오성, 앞의 글, 22-27면을 요약 및 재구성하였다.

32) 권영환, “통상임금 법리 중 고정성 판단과 관련한 추가적인 조건의 문제(토론문)”(미공간), 해밀 2017. 11. 1.자 판례공부모임, 5-7면.

자와 근로자의 약정만으로 성립하고, 다만 근로자가 약속한 근로를 제공하지 못한 경우 쌍무계약의 이행상의 견련성에 따라 근로를 제공하지 못한 부분에 상응하는 임금이 공제(控除)될 수 있을 뿐이다. 또한 민법 제656조 제1항은 “보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체없이 지급하여야 한다.”고 규정하여 고용계약의 보수의 지급기일을 후불로 정하고 있을 뿐이지, 보수에 관한 채권의 성립 자체를 노무의 종료 이후로 미루고 있지도 않다. 이러한 점들을 고려해 볼 때, 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’은 정기상여금 채권의 성립에 관한 약정의 기본적 내용을 구성하는 것이 아니라 그러한 기본약정에 부가된 부관(附款)으로 이해함이 옳다. 따라서 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’이 무효로 되는 경우에는 정기상여금의 지급에 관한 약정은 당연히 조건이 없는 계약으로 존속하며, 따라서 그 지급일 이전에 퇴사한 자도 정기상여금 청구권을 유효하게 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.

(2) 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 문제점

고정급의 정기상여금에 ‘재직 조건’을 붙이는 것이 허용되는지와 관련하여서는 ①임금 매월 정기일 지급의 원칙, ②금품청산의 원칙 및 임금 전액지급의 원칙, ③강제근로금지의 원칙의 각각의 관점에서 검토할 필요가 있다.

1) 임금 매월 정기일 지급의 원칙과의 관계

앞에서 본바와 같이, 필자는 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가로 ‘정기일지급 임금’에 해당하며, 따라서 수개월의 간격으로 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리에 따라 정기상여금 명목의 금품을 매월의 임금 지급일에 안분하여 지급하는 취지로 전환될 수 있을 뿐이라고 생각한다. 이와 같이 고정급의 정기상여금을 소정근로의 대가로 이해한다면, 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자도 당연히 퇴직 전에 제공한 근로에 상응하는 정기상여금의 지급을 청구할 수 있어야 한다.³³⁾ 즉, 정기상여금의 지급일 이전에

근로자가 퇴직한 경우, 사용자는 원래는 근로자가 퇴직한 날의 이전 월의 임금 정기지급일에 그 날까지 제공한 소정근로에 대응하는 정기상여금의 일부분을 지급할 의무를 부담하고 있던 것이고, 다만 ‘위법하게’ 그 지급을 미루고 있던 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 정기상여금에 붙은 ‘채직 조건’은 정기상여금 중 근로자가 이미 제공한 소정근로에 관한 부분, 특히 이미 이전 월의 임금 정기지급일에 구체적인 임금채권으로 성립한 임금을 사후적으로 상실토록 하는 것으로 허용될 수 없다고 생각한다.³⁴⁾

2) 임금 전액지급의 원칙 및 금품청산의 원칙 관련

근로기준법 제36조는 “사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖에 일체의 금품을 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다. 따라서 근로자가 퇴직하는 경우 사용자는 근로자의 재직기간 중의 근로에 관하여 발생한 임금을 지급하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가이며, 따라서 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자가 퇴직 전에 제공한 근로에 상응하는 정기상여금은 퇴직 시점에서 구체적인 임금채권으로 확정된다고 할 것이므로, 고정급의 정기상여금에 ‘채직 조건’을 부가하는 것은 위 근로기준법 제36조의 취지를 몰각하는 것이다. 또한 김기선 박사가 적절하게 지적한 것처럼 모든 임금은 근로의 대가로 지급되는 것이고, 상여금 또는 수당의 임금성이 긍정되는 이상 지급기준일 이전에 퇴직한 근로자에게도 퇴직시점까지의 근로의 대가는 해당 기간의 근로제공일수 비율에 따라 지급되어야 한다. 이러한 점에서 ‘채직 조건’은 근로자가 근로제공의 대가로 지급받아야 할 임금을 사전에 포기토록 하는 약정으로 무효라고 할 것이다.³⁵⁾

33) 대법원 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결.

34) 임종률 교수도 임금 매월 정기일 지급의 원칙과 관련하여 “수개월에 1회씩 지급되는 상여금의 지급 기일 전에 근로자가 퇴직한 경우 그 상여금을 지급해야 하는지가 문제될 수 있다. 그러나 상여금이 근로의 대가로서의 성격을 가지고 있는 이상 지급기일 전에 퇴직하더라도 그 산정기간에 실제 근무한 일수나 그 밖의 산정기준에 따라 상여금을 지급해야 한다. 따라서 상여금 지급기일에 재직할 것을 그 지급조건으로 정하는 것은 원칙적으로 무효라고 보아야 할 것이다.”라고 기술하고 있다(임종률, 앞의 책, 418면).

3) 강제근로금지의 원칙과의 관계

정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’을 유효하다고 인정할 경우, 이러한 ‘재직 조건’은 퇴직을 하려는 근로자로 하여금 정기상여금의 지급일까지는 근로를 하도록 사실상 강제함으로써 퇴직에 관한 의사결정의 자유를 제한하는 결과를 초래하게 된다. 격월 내지 매분기별로 지급되는 정기상여금의 경우 그 지급일까지의 계속 근로를 유도해야 할 회사 측의 합리적인 경영상 필요성이라는 것은 인정될 수 없다는 점에서 정기상여금에 ‘재직 조건’을 붙이는 것은 강제근로 금지의 근본 취지에 위배되며 사회질서에 반하는 행위로서 무효이다.³⁶⁾

(3) 소결

정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 유효성에 관하여, 재직조건을 일률적으로 위법무효 또는 적법유효하다고 볼 수는 없고 재직조건을 두어야 할 ‘합리적인 필요성’과 그로 인하여 ‘근로자가 입게 되는 손실’의 정도를 비교형량하여야 한다는 견해가 있으나,³⁷⁾ 정기상여금에 ‘재직 조건’을 붙이는 방법으로 ‘임금을 비임금화’하는 것은 임금 매월 정기일 지급의 원칙, 금품청산의 원칙 내지 임금의 사전포기에 대한 제한, 강제근로금지의 원칙의 각 측면에서 근로기준법의 명문규정은 물론 공서(公序)에도 반한다는 점을 고려할 때 적어도 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’은 무효로 보아야 할 것이다.

한편, 정기상여금 지급약정에 붙은 ‘재직 조건’의 적법성에 관하여 일본의 판결들로부터 시사점을 구하려는 입장이 있는바, 일본의 경우 일본루세루(ルセル) 사건에서 동경고등재판소가 상여금은 근로자의 근로의 대가로 사용자가 그 지급을 의무화한 임금의 일부이고 지급일 당시 재직하지 않는 근로자에게도 사용자는 지급의무를 진다고 판단하는 등 정기상여금에 재직 조건을 부가

35) 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015, 64면.

36) 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동판례비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015, 56면.

37) 최파라, “재직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 『법조』, 제64권 제7호, 법조협회, 2015. 7, 177면.

하는 것이 위법하다고 보았으나,³⁸⁾ 근래에는 재직 조건의 유효성을 인정하고 있다.³⁹⁾ 그러나 이는 일본의 정기상여금 지급관행이 사용자가 정기상여금의 금액을 정하기 전까지 근로자에게 구체적인 임금청구권이 발생하지 않는 방식으로 우리나라와 상이한 데 기인한 것이므로 우리나라의 고정급 형태의 정기상여금에 ‘재직 조건’을 붙이는 것이 적법한가의 문제에 대해서는 일본의 판례를 원용할 바는 못 된다.⁴⁰⁾ 앞서 본 바와 같이 일본의 경우 정기적으로 지급되고 또한 그 지급액이 확정된 금품은 그 명칭에도 불구하고 상여로 보지 않으므로 정기상여금 지급약정에 붙은 ‘재직 조건’의 적법성에 관한 일본의 판례는 우리나라의 상황에서는 성과급으로 지급되는 가변적인 상여금(예컨대, 국내의 다수의 기업에서 ‘Profit bonus’나 ‘Profit sharing’의 명목으로 지급하고 있는 연말상여금 등)에 관해서나 참고할 가치가 있을 것이다.

2. 판결의 경향

(1) 2013년 전원합의체 판결

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결은 ‘재직 조건’이 붙은 수당의 통상임금성에 관하여 “근로자가 소정근로를 했는지 여부와는 관계없이 지급일 기타 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하기로 정해져 있는 임금은 그 특정 시점에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건이 된다. 그러한 임금은 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는 반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 것이 일반적이다. 그와 같은 조건으로 지급되는 임금이라면, 그 임금은 이른바 ‘소정근로’에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로

38) 東京高裁 1974(昭49). 8. 27.

39) 대표적으로 大和銀行事件: 最高裁第一小 1982(昭57). 10. 7. 등.

40) 일본에서도 사용자가 재직 조건을 남용한 경우에는 지급일 이전에 퇴직한 근로자도 상여금의 지급을 청구할 수 있다는 견해도 있다(대표적으로 西谷 敏, 勞働法(第2版), 日本評論社, 2013, 271면).

자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 그 특정 시점이 도래하기 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하여 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부는 불확실하므로, 고정성도 결여한 것으로 보아야 한다.”고 판시하였고, 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결은 설·추석상여금(통상임금의 50%), 하계휴가비(50만원), 개인연금지원금(월3만원), 단체보험료(월1만원), 선물비(설·추석10만원한도), 생일자지원금(3만원) 등에 관하여 “이들 임금의 지급에 있어 지급일에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건으로 부가되어 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 지급일에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 않는 반면, 지급일에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 이를 모두 지급하기로 하는 명시적 또는 묵시적 노사합의가 이루어졌는지 또는 그러한 관행이 확립되어 있는지를 살펴보았어야 할 것”이라고 판시하였다.

이들 판결은 어떠한 합리적 이유도 제시함 없이 ‘재직 조건’이 붙었다는 이유만으로 수당의 통상임금성, 나아가 그 임금성을 부정하였는데,⁴¹⁾ 이는 근로기준법의 강행규정성을 무용지물로 만드는 역할을 하는 것으로 정당성을 인정하기 어렵다.⁴²⁾

(2) 2013년 이후의 하급심 판결들

위 전원합의체 판결들이 선고된 이후, 다수의 하급심 재판에서 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성이 다투어졌으나, 대부분의 경우에는 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 유효성에 대하여는 아무런 판단을 하지 않은 채 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금이 통상임금에 해당하는지를 판단하였고, 대부분의 경우 그 통상임금성을 부정되었다.⁴³⁾ 논리적으로 보면 ‘재직 조건’이 붙

41) 이달휴 교수는 이러한 상황을 ‘임금의 비임금화성’이라고 지적한바 있다(이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 『법제』 제664호, 법제처, 2014. 3. 15면).

42) 이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 『노동법학』, 제49호, 한국노동법학회, 2014. 3. 19면 이하 참조.

43) 서울고등법원 2016. 4. 8. 선고 2015나2045114 판결; 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2012가합88902 판결; 서울남부지방법원 2016. 4. 21. 선고 2015나54153 판결; 서울남부지방법

은 정기상여금의 통상임금성의 판단 이전에 ‘재직 조건’의 유효성이 먼저 판단되어야 함이 당연하나, 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 통상임금성이 문제된 대부분의 사건에서 법원은 ‘재직 조건’의 유효성에 대한 판단없이 ‘재직 조건’이 유효하다고 전제하고 정기상여금의 통상임금성을 판단하였다는 점에서 문제가 있다.

반면, 그 이유에서는 그 내용을 달리하지만 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금도 통상임금에 포함된다는 취지의 판결도 있다. 예컨대, 부산지방법원 2014. 10. 10. 선고 2011가합27496 판결은 “재직요건이 임금의 지급 조건이 되어 소정근로의 대가성과 임금의 고정성이 결여되었다고 평가하기 위해서는 그러한 임금이 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는 반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 형태여야 하는바, 여기에는 주로 명절수당, 휴가수당과 같이 특정시점에 특별한 목적의 필요에 대응하여 지급되는 복리후생적 성격이 강한 수당들이 해당된다고 봄이 상당하다. 그런데 피고는 소속 근로자들이 특정시점에 재직한다는 사실만으로 정기상여금 전액을 지급한 것이 아니라 근로자들의 결근 등의 사유가 발생한 경우 근로일수에 따라 일할 계산하여 지급하였는바, 이 점에 비추어 보더라도 정기상여금이 재직요건이 부가된 임금으로서 소정근로의 대가성 및 고정성이 결여된 것이라고 보기는 어렵다.”고 판단하였고,⁴⁴⁾ 서울북부지방법원 2015. 7. 15. 선고 2014가합20572 판결(삼양교통 사건)은 “정규직 근로자인 원고들에게 있어서 퇴직이라는 조건은 상당히 이례적인 것이어서, 그러한 이례적 사정에 따라 지급이 제한되는 경우가 근로관계를 형성한 이상 필연적으로 한 번은 있을 수 있다고 하여 이 사건 상여금이 소정 근로의 대가성이 없는 금품이라거나 근로자의 특수하고 우연한 사정에 좌우되는 우발적·일시적 급여라고 보기 어렵다.”고 판시하였다.⁴⁵⁾ 다만 이 판결은 항소심에서 번복되었다.⁴⁶⁾

원 2016. 8. 25. 선고 2013가합12557 판결; 대구고등법원 2015. 4. 1. 선고 2014나21503 판결; 부산고등법원 2014. 1. 8. 선고 2012나7816 판결 등.

44) 이 판결에 대한 평석으로는 김홍영, “재직자 조건이 부가된 정기상여금과 통상임금”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015, 113면 이하 참조.

45) 이 판결에 대한 평석으로는 김홍영, “정기상여금에 재직자 조건이 붙어도 통상임금 인정”,

(3) 2017년 대법원 판결

2013년 이후 다수의 하급심 재판에서 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성에 관한 판단이 엇갈리고 있던 상황에서, 대법원은 2017. 9. 26. ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금은 통상임금에 해당하지 않는다는 취지로 2개의 판결을 선고하였다.

“이 사건 상여금은 지급기준일에 재직 중인 근로자에게 지급하는 임금으로서 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부도 불확실하므로, 통상임금에서 요구되는 고정성이 결여되었다고 볼 수 있고, 따라서 통상임금에 포함된다고 할 수 없다.”⁴⁷⁾

“이 사건 상여금은 지급일 현재 재직하고 있는 근로자에게만 지급되고 근로자가 근로를 제공하더라도 지급일 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 고정성도 인정되지 않고, 이 사건 보전수당은 근로기준법의 개정으로 유급휴가가 감소한 것을 보전해 주기 위해 마련된 것으로서 근로와 무관하게 특정한 시점에 재직한 근로자에게 지급되므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려워 모두 통상임금에 해당하지 않는다.”⁴⁸⁾

이러한 판결들의 당부(當否)를 떠나 ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금은 통상임금으로 볼 수 없음이 대법원의 입장이라는 점만은 명료해 보인다.

3. 검토

‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 판단하기 위해서는 논리적

『노동판례리뷰 2015』, 한국노동연구원, 2016, 123면 이하 참조.

46) 서울고등법원 2016. 4. 8. 선고 2015나2045114 판결. 이에 원고가 상고하여 현재 대법원 2016다220426호로 계속 중이다.

47) 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결.

48) 대법원 2017. 9. 26. 선고 2016다238120 판결.

으로 그러한 ‘재직 조건’의 적법성에 관한 판단이 선행되었어야 한다. 그러나 위 2017년 대법원 판결들은 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’의 적법성 및 유효성을 소여(所與)로 전제한 후, 그 통상임금성(나아가 임금성)을 부정하였다. 특히 위 판결들은 임금의 지급일 이전에 퇴직한 경우 이미 제공된 근로에 상응하는 임금은 당연히 지급되어야 한다는 일반적인 이해(금품청산의 원칙을 떠올려 보라)와는 정반대로 지급일 이전에 퇴직한 자에게는 지급하지 않는다는 조건이 붙은 금원은 소정근로의 대가가 아니라도 판단하였다. 이러한 판단은 사용자가 근로자에게 지급하기로 약속한 금품의 성격이 무엇인가를 정면으로 살피지 않고 그러한 금품의 지급에 ‘재직 조건’이 붙어 있다는 이유로 그러한 금품의 통상임금성(나아가 임금성)을 부정하였다는 점에서 역전(逆轉)된 논리를 보여준다.

V. 결론

‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 부정한 2017년의 대법원 판결들은 근로의 대가인 임금은 그 지급일 이전에 퇴직하더라도 이미 제공된 근로에 상응하는 부분은 당연히 지급되어야 한다는 일반적인 이해와는 정반대로 그 지급일 이전에 퇴직한 자에게는 지급하지 않는다는 조건이 붙은 금원은 소정근로의 대가가 아니라는 논리를 취하고 있다는 점에서 근본적인 문제가 있다.

통상임금의 판단은 법문에 따라 ①임금성 → ②정기성 → ③일률성의 3단계의 판단구조를 따라야 하며, 그것으로 족하다. 판례가 언급하는 ‘고정성’은 일률성(一律性)의 내용을 구성하는 요소로 고려될 수 있을 뿐, 통상임금 여부를 판단하는 추가적인 ‘요건’으로 보아서는 아니 된다. 법령이 예정하지 않은 ‘고정성’이라는 모호한 개념을 통상임금의 요건의 하나로 추가하는 것은 통상임금의 범위를 당초 입법자가 예상보다 부당하게 좁히는 결과를 초래한다는 점에서 동의하기 어렵다. 미국 FLSA §7(e)(3)(a)이 시사하듯, 통상임금의

산정에 포함되는 정기상여금 여부를 판단함에는 ‘상여금 지급에 대한 기대(an expectation of payment)’만 있으면 충분한 것이지, ‘고정성’이 논리 필연적으로 요구되는 것은 아니다. ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 경우 근로자는 그러한 정기상여금의 지급에 대한 정당한 기대를 갖는다는 점을 고려할 때, ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 부정할 위 2017년의 대법원 판결들은 통상임금의 인정범위를 지나치게 협소하게 보았다는 점에서 동의하기 어렵다.

주제어 : 상여금(bonus), 정기상여금(regular bonus), 통상임금(ordinary wages), 재직 조건(incumbent condition), 임금 매월 정기일지급의 원칙(the principle of regular payment)

투고일(2018. 6. 3일), 수정일(2018. 6. 15일), 게재확정일(2018. 6. 21일)

참고문헌

- 김유성, 노동법I, 법문사, 2005.
- 이승길, 미국의 노동법제, 한국경영자총협회, 2005.
- 임종률, 노동법(제14판), 박영사, 2016.
- 하경효, 임금법제론, 신조사, 2013.
- 권오성, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 『노동법논총』, 제41집, 한국비교노동법학회, 2017. 12.
- 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015.
- 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동판례 비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015.
- 김성진, “통상임금의 본질개념으로서의 통상성”, 『노동법포럼』, 제11호, 노동법이론실무학회, 2013. 10.
- 김홍영, “상여금의 임금성 여부”, 『노동법연구』, 제21호, 서울대학교 노동법연구회, 2006. 12.
- 김홍영, “재직자 조건이 부가된 정기상여금과 통상임금”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015.
- 김홍영, “정기상여금에 재직자 조건이 붙어도 통상임금 인정”, 『노동판례리뷰 2015』, 한국노동연구원, 2016.
- 도재형, “통상임금의 범위-상여금을 중심으로-”, 『노동법연구』, 제7호, 서울대학교 노동법연구회, 1998. 5.
- 이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 『법제』 제664호, 법제처, 2014. 3.
- 이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 『노동법학』, 제49호, 한국노동법학회, 2014. 3.
- 정현수, “임금채권의 보호”, 『재판자료 제39집: 근로관계 소송상의 제문제(상)』, 법원도서관, 1987.
- 최파라, “재직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 『법조』,

제64권 제7호, 법조협회, 2015. 7.

片岡昇(송강직 역), 노동법, 삼지원, 1995

菅野和夫(이정 역), 일본노동법, 법문사, 2007.

菅野和夫(이정 편역), 고용사회와 노동법, 박영사, 2001.

西谷 敏, 労働法(第2版), 日本評論社, 2013.

厚生労働省労働基準局 編, 労働基準法解釋總覽(改訂15版), 労働調査會, 2014.

公益財団法人 連合總合生活開發研究所, 『日本の賃金－歴史と展望－』, 2012. 5.

野原香織, “日本工場法における就業規則法制の成立”, 『法學研究論集』, 第44号,

2016. 2.

국문초록

‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성

권 오 성

고정급 형태의 정기상여금은 실질적으로는 소정근로의 제공에 대하여 지급하기로 약속한 소정임금의 성격이 강하다. 정기상여금을 소정근로에 대한 대가로 이해할 경우 이러한 금품은 ‘매월 정기일지급 임금’에 해당한다고 볼 수 있다. 따라서 1개월을 초과하는 기간을 지급주기로 하여 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항 본문에 위반한다. 이러한 정기상여금에 ‘재직일 조건’을 붙이는 방법으로 ‘임금을 비임금화’하는 것은 매월 정기일지급 임금, 금품청산의 원칙, 임금채권의 사전포기의 금지, 강제근로의 금지 등 근로기준법의 강행규정과 공서(公序)에 반한다. 따라서 정기상여금에 붙은 ‘재직 조건’은 위법·무효라고 할 것이다. 이러한 관점에서 보면, ‘재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 부정한 2017년의 대법원 판결들은 임금의 지급일 이전에 퇴사하더라도 이미 제공된 근로의 대가는 당연히 지급되어야 한다는 일반적인 이해와는 정반대로 임금 지급일 이전에 퇴직한 자에게는 지급하지 않는다는 조건이 붙은 임금은 소정근로의 대가가 아니라고 판단하였는바, 이는 사용자가 근로자에게 지급하기로 약속한 금품의 성격이 무엇인가를 직접적으로 살피지 않고 그러한 금품의 지급에 ‘재직 조건’이 붙어 있다는 이유로 그러한 금품의 통상임금성을 부정하였다는 점에서 문제가 있다.

Abstract

The Regular Bonus with the Incumbent Condition and the Ordinary Wages

Kwon, Oh Seong

The regular bonus could be merely paid at regular intervals by being accumulated to correspond to the fixed work schedule. Therefore regular bonus is paid for contractual working and can not be accepted in the concept of the ‘discretionary bonus’. That means regular bonus of fixed type payment is a deferred payment wage paid later after accumulating rewards of contractual working for months. So regular bonus of that type is under the principle of regular payment on wages and such a payment system would violate the Labor Standards Act. And the addition of the ‘incumbent condition’ to regular bonus would violate the provisions of the Labor Standards Act. Thus, if the incumbent condition added to the regular bonus means it would be not paid to the full extent of the regular bonus, that condition may be invalid as unlawful condition. It can only be interpreted that the portion corresponding to the period which is not providing the predetermined work would be reduced and not be paid.